

1512819-03.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1512819-03.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512819-03.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2252092/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 20274546 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 2252092 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia 15 de setembro de 2021, por volta de 14h45, na Rua Ema, 112, bairro Jardim dos Lírios, nesta cidade, ter em depósito, para fins de tráfico, drogas (111 invólucros da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) "maconha"), substâncias que provocam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia em 04 de novembro de 2021, fls. 166/167, o réu foi citado (fls. 185).

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se Defesa e Acusação.

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e

autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 223/225).

A Defesa reclama a absolvição por falta de provas. O réu era usuário de maconha, não vivia da mercancia, apenas "guardava" as drogas para o seu consumo pessoal. Alternativamente, desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, aplicando-se a medida educativa menos gravosa. Para o caso de condenação, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programas ou cursos educativos, observados os prazos máximos de 5 e de 10 meses.

Subsidiariamente, pena mínima, ou ainda, nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (fls. 229/232).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Verifica-se que na fase administrativa o réu permaneceu em silêncio (fls. 122).

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lanço aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Em juízo, Lucas não se dignou em comparecer para interrogatório e eventualmente apresentar escusa hábil a excluir a ilicitude ou a culpabilidade da conduta. Teve declarada à revelia (fls. 217/218).

A sua ausência não comprometeu o contexto probatório.

Ana Paula Alves de Oliveira, ouvida apenas na fase de inquérito, alegou que estava no local dos fatos com uma amiga, iriam consumir crack. Tinham oito pedras, consumiu duas. Foi abordada por policiais, que encontraram as seis pedras restantes. Sua amiga já havia deixado o local. Não conhecia pessoa conhecido pela alcunha "Cabelo", não estavam juntos. Desconhecia a origem das maconhas encontradas, essa droga não lhe pertencia (fls. 06).

O policial civil Emerson esclareceu que receberam denúncia, via linha telefônica direta da base, que noticiava que um casal traficava na esquina das Ruas Ema com Violetas, no bairro Jardim dos Lírios. Foram noticiadas as características dos suspeitos e que o homem tinha o apelido de 'Cabelo'. Diligenciaram até o local denunciado com uma viatura descaracterizada. O logradouro tinha elevado índice de venda de entorpecentes, permaneceram a uma certa distância, posicionaram atrás de uma creche ali existente. Durante a observação velada à distância, conseguiram definir que realmente existia uma pessoa do sexo masculino e outra do sexo feminino, com uma movimentação característica àquelas observadas em pontos de vendas de entorpecentes. Transeuntes procuravam o casal na esquina, conversavam brevemente e eles pegavam o dinheiro. A partir daí, eles se deslocavam à pé, da esquina até uma casa, que distava aproximadamente vinte ou trinta metros da Rua Ema. Entravam na residência e voltavam até a esquina. A pessoa que havia feito o contato e entregado o dinheiro inicialmente, recebia algo em troca e ia embora. Após observarem umas três movimentações e terem conseguido determinar a casa em que o casal ficava entrando e saindo, optaram por abordá-los. Fizeram a volta pelo quarteirão da creche e foram até esquina onde eles estavam. Como não os

encontraram, foram até a porta da residência, pois o portão estava aberto. Anunciaram-se como policiais e entraram pelo corredor do portão. Naquele momento, chegou uma mulher que se identificou como moradora da casa. Explicaram que receberam uma denúncia de tráfico e que um dos envolvidos era conhecido pela alcunha de 'Cabelo'. Após observação velada, identificaram que duas pessoas entravam naquele imóvel reiteradamente. A moradora explicou que 'Cabelo' era o apelido do seu irmão, Lucas Henrique. Ela explicou que Lucas morava ali, mas ficava o dia inteiro na rua. Lucas apresentava problemas de disciplina, ante a sua proximidade com o mundo das drogas.

Nesse momento, chegou a genitora de Lucas, então solicitaram autorização para a realização de buscas no imóvel, o que foi autorizado. As mulheres indicaram onde era o quarto do acusado, acompanhando-os até onde ficavam os seus pertences. Havia uma caixa de sapatos no chão, bem próximo da porta do quarto, onde encontraram um invólucro, com aproximadamente 110 porções de maconha. Em seguida, voltaram para a rua, tentavam localizar os suspeitos. A mulher os avistou saindo da residência e correu, sentido à Rodovia SP 304. Fizeram um breve acompanhamento, ela foi alcançada e abordada nas margens da Rodovia. A mulher não reagiu. Questionada se portava algo ilícito, ela admitiu que trazia algumas pedras de crack, em torno de seis, fornecendo-as para a equipe. A mulher foi presa, algemada e conduzida até a Delegacia. Lucas não foi localizado naquela ocasião. Ele foi qualificado indiretamente, com o auxílio de sua genitora. No curso do processo, foi expedido o mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado. Fizeram algumas campanhas nos arredores da residência do réu, ele foi localizado nas imediações da sua casa. Em data posterior ao flagrante, Lucas foi preso preventivamente, em cumprimento ao mandado expedido pelo Poder Judiciário. Indagado, Lucas alegou que não tinha nenhum tipo de envolvimento com o tráfico, que era apenas usuário de drogas, contrariando as informações de sua genitora. O acusado não soube explicar o grande volume de drogas encontradas em seu quarto, dentro dos seus pertences pessoais. As buscas foram acompanhadas pela mãe e pela irmã do acusado. Inicialmente, elas ficaram nervosas, a genitora passou mal e foi amparada pela filha. Após o encontro dos entorpecentes, elas relataram que Lucas tinha várias ocorrências policiais devido ao seu envolvimento com o mundo das drogas. O quarto era utilizado por Lucas, as drogas estavam dentro de uma caixa de tênis que pertencia ao acusado. A mãe e a irmã do acusado disseram que eram pessoas trabalhadoras e voltavam do serviço no momento da diligência policial. Elas nunca tinham visto drogas de perto. As mulheres concluíram que as drogas pertenciam ao acusado. Não conhecia ao réu. André Luís Miyazaki, outro policial civil, ratificando a versão do colega, lembrou-se de que receberam informações na Delegacia, noticiando que pessoa conhecida pelo vulgo 'Cabelo' estaria traficando nas imediações da Rua Ema com a Rua Violetas. Informaram a vestimenta que ele trajava, bem como foi fornecido o detalhe de que a droga comercializada no ponto de venda era armazenada na casa dele. Foram até o endereço informado com uma viatura descaracterizada e realizaram breve campanha. Observaram ele entrando e saindo do imóvel e mantinha contato com uma mulher no ponto de tráfico. Perderam o contato visual e entraram na casa do acusado. No momento em que Lucas percebeu que entravam na casa dele, ele correu com a mulher do ponto de drogas. O imóvel ficava nos fundos e explicaram a situação para a irmã do acusado, que franqueou a entrada da equipe e explicou que o réu estava dando trabalho para a sua genitora. A irmã de Lucas acompanhou as buscas na residência. Encontraram maconha na casa. A mãe de Lucas chegou no imóvel, conversaram com os seus familiares. Não se recordava a roupa que o réu trajava naquela ocasião, mas passaram a descrição para a genitora de Lucas, que confirmou que era essa a vestimenta que o seu filho tinha saído de casa, no período da manhã. A irmã de Lucas confirmou que ele era conhecido pelo apelido de 'Cabelo'. Realizaram diligências pelo bairro e encontraram a mulher que estava na mercancia com Lucas, na beira da Rodovia SP 304. Ela foi abordada e revistada. Em seu poder, localizaram algumas porções de crack. A mulher foi conduzida até a Delegacia, onde foi elaborado o flagrante e a autoridade representou pela prisão de Lucas, vulgo 'Cabelo'. No dia seguinte, o Poder Judiciário expediu mandado de prisão em desfavor do acusado. Dois dias depois, realizaram diligências e localizaram Lucas, ele

estava dormindo na casa dele, onde foi preso.

A prova, pois, é segura e convincente quanto a responsabilidade criminal do acusado.

Embora não tivesse ocorrido prisão em flagrante, exatamente porque o réu se evadiu da ação policial, experientes policiais civis investigaram o episódio, após denúncia de tráfico, com a prisão de uma envolvida (Ana Paula), após observação velada, com a identificação do réu, conhecido pelo vulgo 'cabelo'.

Deveras, durante a diligência, os policiais civis ingressaram na casa onde o viram em movimentação suspeita com a mulher e localizaram, no quarto onde o réu dormia, uma caixa de sapatos, contendo em seu interior 111 invólucros de maconha.

Parentes do réu, mãe e irmã, confirmaram os trajes que ele vestia na ocasião da informação anônima de tráfico, correspondendo ao visto pelos policiais civis. Na casa do réu, apontado o seu quarto e onde dormia, os policiais encontraram alentada quantidade de drogas, embaladas em porções e propícias à venda imediata. Também no mesmo dia, os policiais encontraram a mulher, implicada igualmente com o crime e com ela apreenderam outro tanto da mesma droga.

Presa a mulher, foi representada pela prisão preventiva do réu, deferida. Ao depois, dois dias, o réu foi localizado em sua casa e preso.

A quantidade, variedade e disposição, não permite inferir conclusão outra senão a de que se destinassem ao tráfico, não se olvidando que o réu foi denunciado anonimamente, com apelido, em tudo correspondendo.

A alegação de que a droga seria para uso próprio, não foi provada e muito menos é crível, pela citada forma em que estavam embaladas e quantidade, repetindo que havia acusação de tráfico, visualizada em campanha oportuna realizada por policiais civis e suspeitosa fuga, na data da busca.

O réu silenciou na fase policial e em Juízo sequer se interessou em comparecer para interrogatório e acompanhar a instrução.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao inculpatado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

Também:

"Quem invoca um álibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (TJSP, AP. 53.726, Rel. Azevedo Franceschini).

A conduta é assim mesmo a de tráfico, não sendo necessário, para a hipótese, que o réu estivesse vendendo drogas. A acusação é pontual em alegar que mantinha em depósito drogas, para a mercancia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a

substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Também, relembre-se e se repete, o fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

A prova, enfim, é boa e suficiente, com prisão em flagrante delito, certeza visual do delito, apreensão da droga, e depoimentos de policiais.

A versão dos policiais civis, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Note-se que o réu sequer ousou apresentar versão na única oportunidade em que foi interrogado.

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo laudo de constatação (fls. 13/15), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 125/127).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

Na primeira fase, observo que o réu é multirreincidente. Apenas uma condenação será considerada para reincidência (Processo nº 0005668-12.2011.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III, ambos do(a) SISNAD, com trânsito em julgado para a Defesa em 10/07/2014). A outra, embora apta para o mesmo fim, para evitar 'bis in idem' será considerada como circunstância judicial, evidenciando os seus maus antecedentes, de há muito.

Assim já se pacificou que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado.

"O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.". (TJDF APR 10250110093863; no mesmo sentido, STJ, HC 306.222/RS).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Aumento a pena base em um sexto, pelos maus antecedentes.

Na segunda, pela reincidência específica (Processo nº 0015143-84.2014.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 33 "caput", do(a) SISNAD, com trânsito em julgado para a Defesa em 09/12/2015), aumento a pena em mais um sexto.

Em terceira e última fase, impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque reincidente. E a pena final, por si, impõe óbice a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis. O réu deverá cumprir pena no regime inicial fechado, pela mesma reincidência.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, condenando-o às penas de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão, regime inicial fechado e seiscentos e oitenta (680) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 61, I do Código Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 144).

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado, se o caso.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Faculto recurso em liberdade, porque assim o réu vem respondendo aos atos do processo.

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 28 de março de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA